

**باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية**

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٠٩م ، الموافق ٣ ربيع الآخر ١٤٣٠هـ ،

برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش ، ومنير السيد منصور ،
ومحمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ، وسلمان عيسى
سيادي ، ضحى إبراهيم الزباني ، أعضاء المحكمة .
وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٦/٣ لسنة (٤) قضائية .

المقامة من :

ساشا أدريان بروكس وكيله المحامي سعد عبدالله الشمالان .

ضد

(١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية.

(٢) النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ٢٠٠٦ م أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية عجز نص الفقرة (د) من المادة (٢٣) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤ بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٣ بتعديل المادتين ٢٣، ٢٤ من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٣ بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، في ما نصت عليه من أنه " ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة (٧٢) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات ".

قدم ممثل دائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من أجنبي، وفي الموضوع برفض الدعوى.

ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم في جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى المحكمة الكبرى الجنائية بموجب الدعوى الجنائية رقم ٣٧١٤ لسنة ٢٠٠٦ لأنه بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢١ بمملكة البحرين؛ حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهرأ مخدراً (كوكايين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبته بالمواد (١) و (٢) و (١/٢٣) - "ج" و (١/٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٣ بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤ والجدول رقم (١) الملحق به. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية النص الوارد بعجز الفقرة (د) من المادة (٢٣) سالفه الذكر. وبجلسة ٢٠٠٦/١١/٢ قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ٢٠٠٦/١٢/٣ وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهر فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٥.

وحيث إن دائرة الشئون القانونية دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها من أجنبي (بريطاني الجنسية)، باعتبار أن حق التقاضي وإن جاز منحه للكافة - مواطنين وأجانب - حماية للحقوق التي تمنحها القوانين العادية، إلا أنه في الحقوق الدستورية، يكون حق التقاضي مقصوراً على المواطنين وحدهم لضمان حقوقهم وحياتهم المنصوص عليها في الدستور، مستهدفة بهذا الدفع انكار حق المدعي في رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية. كما طلبت في ختام دفاعها رفض الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من دائرة الشئون القانونية بعدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها من أجنبي فمردود، بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، من أن الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص التشريعية يلزمها بالضرورة، ومن أجل اقتضاها، تمتعها بالحماية التي يكفلها الدستور أو المشرع العادي لها، مما يلقي على عاتق الدولة التزاماً قانونياً بتوفير الوسائل الاجرائية والقواعد الموضوعية التي تمكن أصحاب الحقوق - مواطنين و أجانب - من خلالها من رد العدوان الذي يقع على حقوقهم الثابتة وفقاً لنظمها القائمة. ويتمثل المدخل الطبيعي لتلك الحماية في مبدأ حق التقاضي المقرر بنص الفقرة (و) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل التي تنص على أن " حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون ". فهو نص يدل على العموم والاطلاق ليدخل في حكمه ضمان حق التقاضي للناس كافة - مواطنين و أجانب على السواء - ويشمل كذلك الحقوق جميعها سواء وردت في الدستور أو في القوانين. ومؤدى ذلك ضرورة التلازم بين قيام هذا الحق إلى جانب الحقوق الموضوعية المتنازع عليها، باعتباره وسيلة الحماية الدستورية لهذه الحقوق وفقاً لقواعد الدستور. ومن ثم لايسع الدولة بموجبه أن تتنصل من مقتضياته أو أن تجحد على غير مواطنيها الحق في النفاذ إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم المقررة في تشريعاتها، أو أن توصل دونهم باب اللجوء إلى المحكمة الدستورية طلباً للحماية الدستورية التي نصت عليها المادة (١٠٦) من الدستور المعدل، وطبقاً للأوضاع المقررة في قانون انشائها، حتى لا تكون الحقوق والحريات المقررة لهم في القانون مجردة من وسيلة حمايتها، فيصبح النص عليها بدونها لغواً يُنَزَّه عنه المشرع.

لما كان ذلك، وكان المدعي يستهدف بدعواه القائمة الدفاع عن حقوقه في الحرية الشخصية والعدالة واستقلال القضاء المنصوص عليها في الدستور، ورد العدوان الذي يقع عليها من المشرع، ويطعن على عجز نص المادة (٢٣/د) من المرسوم بقانون السالف البيان مخالفته لحقوقه المذكورة، ولا سبيل له لحمايتها إلا بالالتجاء حصراً للمحكمة الدستورية التي أولاها الدستور وحدها الاختصاص برقابة دستورية القوانين، فإن نطاق الحماية الدستورية يمتد إليه ولو كان غير بحريني، لتلازم ضمان تلك الحقوق مع هذه الحماية، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها من أجنبي غير قائم على سند صحيح متعين الرفض.

وحيث إن المادة (٢٣) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٣ المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤ - وهي المادة التي تضم في عجزها النص التشريعي المطعون عليه - تنص على أن " يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار:

(أ) كل من استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.

(ب) كل من زرع أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.

(ج) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأيّة صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بدون مقابل في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون.

(د) كل من أوكل إليه حفظ مواد أو مستحضرات مخدرة أو رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة (٧٢) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات.

وحيث إن المادة (٧٢) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ تنص على أنه "إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة. فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز انزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له انزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر".

وحيث إن المدعي قدم أثناء نظر هذه الدعوى مذكرة قال فيها إن القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نص في المادة (٥٨) منه على إلغاء المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته، إلا أنه نقل النص محل الطعن حرفياً في المادة (٥٧) منه، مبقياً بذلك على ذات الحكم في النص المطعون عليه في هذه الدعوى بالنسبة للجريمة المسندة للمدعي، مما يجعله خاضعاً لحكم المادة الأخيرة، ومن ثم تتحقق مصلحته في الطعن على نص المادة (٥٧) من القانون المذكور، ويمتد الطعن بعدم الدستورية إليه، وقد أضاف في ختام مذكرته طلب الحكم بعدم دستورية هذا النص، لذات الأسباب التي أبداها في لائحة الدعوى.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.

وحيث إن المدعي أحيل إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهمة المنسوبة إليه، وكان النص التشريعي المطعون عليه يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع بحكم اللزوم إذا ما انتهت إلى القضاء بإدانته، مما حدا بها إلى تقدير جدية الدفع المقدم من المدعي بعدم دستوريته وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على هذا النص،

فمن ثم يرتبط الفصل في دستوريته بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، ويتحقق بالتالي المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في هذه الدعوى.

وحيث إنه لا ينال من توافر مصلحة المدعي في الدعوى الراهنة صدور القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي نص في المادة (٥٨) منه على أن "يلغى المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٣ بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها" إذ أبقى البند (٤) من الفقرة (أ) من نص المادة (٣٠) من القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ السالف البيان، على العقوبة ذاتها بالنسبة إلى الجريمة عينها المنسوب إلى المدعي ارتكابها، كما نص في المادة (٥٧) منه على أنه "لا يجوز للمحكمة عند تطبيق أحكام المادة (٧٢) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المنصوص عليها في أي من المادتين (٣٠) و (٣١) فقرة (ب) من هذا القانون عن السجن لمدة عشر سنوات" مبقية بذلك على ذات مضمون النص المطعون عليه في هذه الدعوى، مما ينتقي معه القول باستفادة المدعي من أعمال قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" أمام محكمة الموضوع، لعدم انطباقه عليه بأثر رجعي، فتنتقي في هذه الحالة مصلحته الشخصية في الطعن على نص المادة (٥٧)، ومن ثم لا يعتبر مطروحاً على المحكمة الدستورية بحكم اللزوم للنظر في دستوريته. ويظل عجز نص المادة (٢٣/د) المطعون عليه من القانون الملغى، قائماً في شأنه، باعتباره النص الساري في نطاقه الزمني وقت ارتكاب الجريمة محل اتهام المدعي، ويتحقق بالتالي مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليه وحده، بصرف النظر عن إلغائه على النحو السالف ذكره.

وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعي امتداد الطعن بعدم الدستورية إلى نص المادة (٥٧) من القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ السالف البيان فغير مقبول، ذلك أن ولاية المحكمة الدستورية - طبقاً لما يقضي به نص المادة (١٨) من قانون انشائها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية عجز نص المادة (٢٣/د) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٤ السالف البيان، وكان التصريح الصادر من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية منحصرأ في هذا النطاق وحده، فإن ما تضمنته مذكرته الأخيرة من طعن على نص المادة (٥٧) من قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ يعتبر طعنأ على غير النص التشريعي الذي تعلق به التصريح الصادر عن محكمة الموضوع، مجاوزأ النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى الدستورية في خصوص الدفع بعدم دستورية نص المادة (٥٧) المذكور، اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها والتي لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جهرية فرضها المشرع، وتتعلق بالنظام العام لضرورة تقتضيها المصلحة العامة، كيما ينتظم التداعي في

المسائل الدستورية وفقاً لها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس بالنسبة إلى النص المذكور.

وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه مخالفته للمادة (٤) من الدستور لمساسه بالعدل، وللمادة (١/٣٢) لإخلاله بمبدأ فصل السلطات، وللمادة (١٠٤) لمخالفته مبدأ استقلال القضاء، وذلك استناداً إلى أن تحقيق العدل الذي هو أساس الحكم - كما وصفه الدستور بنص المادة (٤) منه - يتطلب أن يكون للقاضي مطلق الحرية في تقدير الظروف الخاصة بكل قضية وبالمتهم فيها ومن ثم تحديد العقوبة المناسبة، وأن قيام نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لنص المادة (١/٣٢) من الدستور يعد مانعاً من تدخل المشرع في عمل القاضي وسلطته المتمثلة في تحديد العقوبة المناسبة لوزن الجرم وشخصية المتهم وملابسات وظروف كل قضية على حدة، وعلى أساس أن مبدأ استقلال القضاء وحظر التدخل بأي حال في سير العدالة، إعمالاً لنص المادة (١٠٤) من الدستور، يترتب عليه وجوب امتناع أي سلطة عن إحلال تقديرها محل تقدير القاضي للعقوبة، ومن باب أولى لا يجوز للسلطة التنفيذية إذا أعملت حقها في إصدار مراسيم بقوانين أثناء غياب السلطة التشريعية إعمالاً لنص المادة (٣٨) من الدستور أن تتدخل في سلطة القاضي، سيما وأنها اشترطت في عجزها لصحة هذه المراسيم عدم مخالفتها للدستور.

وحيث إنه من المقرر - وفقاً لقضاء هذه المحكمة - أن الأصل الدستوري لسلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أنها سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها ضوابط محددة تحد من إطلاقها، باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً بينها ومرجعاً ما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحقيق مصالح الجماعة، واختيار أصلحها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. إلا أن ممارسة هذه السلطة مقيدة بضوابط الدستور وحدوده، والتي تعد سياجاً لا يجوز اقتحامه أو تخطيه. فإذا ما عهد الدستور إلى أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية بتنظيم موضوع معين، كان لزاماً على القواعد القانونية التي تصدر عن أي منهما في هذا النطاق ألا تتنازل عن جوهر الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور، سواء بنقضها من أساسها بإهدارها، أو بانتقاصها من أطرافها بتهميشها، وإلا كان ذلك بمثابة عدوان على مجالاتها الحيوية.

وحيث إن السلطة التقديرية التي يباشرها المشرع في مجال تفريد العقوبة تتحقق بوسائل متعددة من بينها التدرج بالعقوبة بين حديها الأعلى والأدنى، ومنها وقف تنفيذ العقوبة، ومنها الخروج على ذينك الحدين صعوداً ونزولاً، فيرتفع بها عن حدها الأعلى في حالة الظروف المشددة، وينزل بها عن حدها الأدنى في حالة الظروف المخففة، ويخضع تقدير ذلك كله للسلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات. ولما كان الدستور قد أكد على مبدأ شخصية العقوبة بنص

الفقرة (ب) من المادة (٢٠) منه، فإنه يعني به - في أحد مضامينه - تقييد المشرع بضرورة وجوب تنظيم مبدأ التفريد التشريعي للعقوبات، وذلك لكي تتناسب العقوبة مع مدى مسؤولية المتهم عن الجريمة شخصياً ودوره في الجرم عند إنزال العقوبة عليه من القاضي. ومن ثم لا مندوحة للمشرع من الناحية الدستورية عن أعمال التفريد للعقوبة في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات، وإلا كان مخالفاً لمبدأ شخصية العقوبة. إلا أن الدستور، وقد ألزم المشرع بتفريد العقوبة، لم يحدد له حداً معيناً عند ممارسته لسلطته في التفريد، ولم يضع عليه قيداً في تحديد مداه ومجالاته وحالاته وأسبابه، وبالتالي ليس ثمة قيد دستوري خاص على مباشرة المشرع لسلطته تلك إلا الضوابط التي يفرضها الدستور في إطار تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات القائم على مبدأي الضرورة الاجتماعية والتناسب في العقوبة. وكلما استقام الجزاء الجنائي على قواعد يكون بها ملائماً، ومبرراً من منظور اجتماعي، فإن إحلال جهة الرقابة على دستورية القوانين لخياراتها محل المشرع في شأن تقرير جزاء أو تحديد مداه لا يكون جائزاً دستورياً. بما مؤداه أن دور الرقابة على دستورية القوانين التي خولها الدستور للمحكمة الدستورية يقف في هذه الحالة عند حد مقابلة النص المطعون فيه بنصوص الدستور الشكلية والموضوعية، لبيان أوجه مخالفتها لها أو اتفاقها معها، ولا يمتد إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث عليه.

وحيث إن النص الطعين قد حدد الحد الأدنى للعقوبة الذي لا يجوز للمحكمة النزول عنه عند تطبيق الظروف المخففة في الجنايات الواردة بنص المادة (٢٣) المذكورة، فإذا رأت ظرفاً يدعو إلى الرأفة بالمتهم، لا يجوز لها النزول بعقوبة الاعدام أو السجن المؤبد عن السجن لمدة تقل عن عشر سنوات، فإن المشرع بهذا التقدير، قد أجرى المفاضلة بين البدائل المختلفة لتفريد العقوبة، مستهدفاً أنسبها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وهي مكافحة جرائم المخدرات، ومن بينها في خصوص الدعوى الماثلة، جريمة تجارة المخدرات، التي تعتبر من أخطر الجرائم فتكاً بالمجتمع، وتدميراً لثروته المادية والبشرية؛ عماد رقيه وتقدمه وازدهاره، فيكون تقديره للعقوبة المناسبة، وفق الأسس الموضوعية التي يراها أصون لمصالح الجماعة، وأحفظ لقيمها، لتكون ردعاً خاصاً لمرتكبيها عن جرائمهم، وزجراً عاماً لسواهم ممن قد تسول لهم أنفسهم الأمانة بالسوء اقترافها، هو من الملاءمات التي تدخل في نطاق سلطته التقديرية التي يمارسها في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات، وفي حدود اختصاصاته الدستورية ووظيفته التشريعية. ولما كان الجزاء الجنائي للجريمة في النص الطعين قائماً على قاعدة التناسب والملائمة، ومبرراً من منظور اجتماعي، فلا يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل تقديرها محل تقدير المشرع في شأن تقريره أو تحديد مداه.

وحيث إن من الثابت كذلك، أن النص قد احتفظ للقاضي بسلطة تقديرية في مجال تفريد العقوبة وتطبيق الظروف المخففة على المتهمين بالجنايات محل النص الطعين عند توافر مبرراتها، فيتدرج بها بين عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات، ويياشر من خلالها سلطته في توقيع العقوبة المناسبة لمسئولية المتهم شخصياً عن الجريمة ودوره فيها، ويقدرها حسب شخصيته وظروفه وعلى ضوء ملابساتها، في الحدود المقررة قانوناً، فذلك هو جوهر الوظيفة القضائية. وبالتالي فإن المشرع لم يلغ سلطة القاضي في تفريد العقوبة، ولم يحجبه أو يحرمه من مباشرة وظيفته القضائية في تقدير العقوبة المناسبة، على تقدير أن سلطة القاضي في تقدير العقوبة وتفريدها ليست سلطة تحكمية، وإنما يياشرها في الحدود الذي يقدرها المشرع في القانون ويمارسها في إطاره.

وحيث إن النص الطعين - وعلى ضوء ما تقدم - قد أكد سلطة القاضي في تفريد العقوبة وتقديرها في الحدود المقررة قانوناً، فإنه يضحى بمنأى عن شبهة المساس بجوهر الوظيفة القضائية واستقلالها أو التدخل في سير العدالة، ولا يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذي نص عليه الدستور في المادتين (٤) و (١٨) منه، لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين السالف ذكرهما. بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي يكون تحكيمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها.

وحيث إن ما تضمنه النص الطعين من اختلاف في المعاملة القانونية بين المحكوم عليهم في الجنايات المنصوص عليها في المادة (٢٣) المذكورة، وبين غيرهم من المحكوم عليهم في الجنايات المختلفة عند تطبيق المحكمة للمادة (٧٢) من قانون العقوبات، كان ضرورياً ومتناسباً مع الأغراض التي توخاها المشرع من هذا التقيد، مستهدفاً فئة من أخطر مجرمي المخدرات، على نحو ماسلف بيانه، فإن النص الطعين - وهو مبني على قاعدة عامة مجردة - يكون مستنداً إلى أسس موضوعية لا تحكم فيها، بما تفتقر معه قالة التمييز إلى ما يقيمها.

وحيث إن النص الطعين لا يتعارض مع أحكام الدستور من أي وجه آخر، فإنه
يتعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٠٩م، الموافق ٣ ربيع الآخر ١٤٣٠هـ. برئاسة السيد/ إبراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : منير السيد منصور، ومحمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، د. ضحى إبراهيم الزباني . أعضاء المحكمة.
وحضور السيد/ عبد الحميد علي الشاعر أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/١/٠٧ لسنة (٤) قضائية.

المقامة من:

نبي بخش سعيد أحمد بخش وكيله المحامي فاضل عبدالله المديفع.

ضد

- (١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية.
- (٢) النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يناير سنة ٢٠٠٧ أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (٨٣) من القانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فيما نصت عليه من أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذه قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون." لمخالفتها لنص الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (٢٠) والفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور. وقدم ممثل دائرة الشؤون القانونية مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في القضية رقم ٢٢٣٦ سنة ٢٠٠٥ ضد المدعي بتهمة استيراد، وتوزيع العدد رقم ٢٧٩ من مجلة (حياة الناس) المنشورة في المملكة العربية السعودية رغم ما تحتويه من أمور خادشة لشرع واعتبار المدعوة "زينب غلوم حسن".

وطلبت عقابه بالمواد ٢/٧٦ ، ٣/٩٢ ، ١/٣٦٥ ، ٣ من قانون العقوبات والمواد ٦٩/ب ، ١/٧٥ ، ٨٢ ، ٨٣ من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية دفع وكيل المدعي بعدم دستورية نص المادة (٨٣) السالف بيانه، وإذ قدرت المحكمة المذكورة جديّة هذا الدفع صرحت لوكيل المدعي بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠ بإقامة دعواه الدستورية خلال شهر ، فأقام الدعوى الراهنة بتاريخ ٢٠٠٧/١/٩.

وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.

ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:

أولهما: أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره - قد لحق به ، سواء أكان هذا الضرر يتهدهد وشيكاً ، أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.

ثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه لما كان المدعي قد أُحيل إلى المحكمة الكبرى الجنائية بوصف أنه في غضون شهري أغسطس وأكتوبر سنة ٢٠٠٣ بمملكة البحرين قام باستيراد المطبوع الممثل في العدد رقم ٢٧٩ من مجلة (حياة الناس) المنشور بالمملكة العربية السعودية بما تضمنه من رمي بإحدى طرق العلانية المجني عليها بما يחדش شرفها واعتبارها خلافاً لأحكام المواد السالف بيانها. وإذ طعن - بعدم دستورية نص المادة (٨٣) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي تنص على أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذه قد نشرت في الخارج، يُعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوعات بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون..." وقدرت المحكمة الكبرى جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فمن ثم يرتبط الفصل في دستورية النص المطعون فيه بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، في هذا النطاق، وتتحقق بالتالي المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في دعواه الماثلة.

وحيث إن المدعي ينعى على نص المادة (٨٣) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ مخالفته :

١- نص الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من الدستور فيما نصت عليه من أن "العقوبة شخصية".

٢- نص الفقرة (ج) من المادة (٢٠) من الدستور فيما نصت عليه من أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".

٣- نص الفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور فيما نصت عليه من أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون".

وشرحاً لذلك قال إن النص المطعون فيه يترتب عليه معاقبة المدعي باعتباره مستورداً وموزعاً للمطبوع الذي تمت طباعته في الخارج بعقوبة الفاعل الأصلي لجريمة النشر - وهي الجريمة التي تضمنتها المادة المنشورة - أي الناشر الموجود بالخارج مما يعد تعدياً على حرية المدعي الشخصية، وكذا يعد مسؤولاً عن فعل اقترفه غيره. فضلاً عن أن النص المطعون فيه مبني على افتراض قانوني للمسئولية الجنائية للمستورد والموزع بافتراض علمه وإطلاعه التام بالفعل عن كل ما نشر حتى ولو لم يطلع فعلاً على المطبوع لأسباب ليس في استطاعته تداركها لكبر حجم المطبوع أو تعدد المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها.

وحيث إن الدستور عهد إلى كل من السلطتين التشريعية والقضائية بمهام قصرها عليهما طبقاً لنص المادة (٣٢/أ) من الدستور المعدل ذلك أن الدستور ناط بالسلطة التشريعية سن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (٣٢/ب) السالف بيانها على أن "السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور"، كما نصت المادة (٧٠) على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك". كذلك أسند الدستور إلى السلطة القضائية ولاية الفصل في المنازعات والخصومات على النحو المبين بالمادتين (١٠٤ و ١٠٥) من هذا الدستور.

وحيث إن الدستور في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها والتفديد بمنهجها التقدمية - عملاً بما جاء بميثاق العمل الوطني - نص في الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها". قد دلّ على أن لكل جريمة ركنها المادي الذي يدور معها في وجودها وفي شرعية عقابها، فلا قوام لجريمة بغير هذا الركن المادي، ولا شرعية لعقوبة بدونه، وهو ما أكدته الفقرة المذكورة بحظر العقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، بما مؤداه حصر دائرة العقوبة في إطار الأفعال أو الامتناع عنها بالمخالفة للقانون، وبهذا النص يُفصح الدستور عن أن أساس التجريم الذي ينبني عليه أي نص عقابي - في زواجره ونواهيه - هو مادية الفعل المعاقب على ارتكابه، إيجابياً كن هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن المسائل التي تنظمها النصوص العقابية في مجال تطبيقها على المخاطبين

بأحكامها محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأنيث وعلته، وهي التي يتم بها التمييز بين الجرائم وبعضها عن بعض، وهي التي تقدر محكمة الموضوع على أساسها طبيعة الجرم، ومقدار العقوبة المناسبة له، بل أن محكمة الموضوع وهي بصدد تقدير توافر القصد الجنائي لا تعزل نفسها عن ركن الجريمة المادي والفعل محل الاتهام الذي يجب إقامة الدليل عليه ابتداءً بصورة قاطعة فتجبل بصرها فيه منقبة من خلال عناصره عما قصد إليه الجاني من وراء ارتكاب الفعل المعاقب عليه ومن ثم فإن الركن المادي هو الذي يكشف بعناصره المادية عن الركن المعنوي وبهما معاً تقدر محكمة الموضوع دور الجاني في الجريمة، فيأتي تقديرها للعقوبة في حدودهما متناسباً مع تورط الجاني في ارتكاب الجرم، وبالتالي لا يتصور وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر العلاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية لا تعتبر واقعة في منطقة التجريم، إلا إذا كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية فليس ثمة جريمة.

وحيث إن الجريمة تعتبر من فعل الغير بالنظر إلى الشخص الذي لم يساهم فيها بعمل مادي سواء باعتباره فاعلاً أو شريكاً، ومن المقرر عدم مسئولية هذا الغير لعدم مساهمته في الجريمة بفعل مادي طبقاً لهذا المعنى.

وحيث إنه لا يكفي لتوافر التجريم أن ينصب على فعل أو امتناع معين، ما لم يكن هذا الفعل وليد إرادة حرة تبعث هذا الفعل إلى الوجود، وتفترض الإرادة الحرة أن تكون وليدة أهلية جنائية يعترف بها القانون فالأصل في الجرائم أنها تعكس تكويناً مركباً من الفعل المادي والإرادة الحرة، وذلك باعتبار أن هذه الإرادة هي التي تتطلبها الأمم المتحدة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركناً في الجريمة وأصلاً ثابتاً كاملاً في طبيعتها وليس أمراً دخيلاً مقحماً عليها أو غريباً عن خصائصها.

واشترط هذه الإرادة يعتبر ضماناً مهماً لحماية الحقوق والحريات في مواجهة سلطة التجريم والعقاب. على أن يلاحظ أن اشتراط الإثم (القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدى) في الإرادة الحرة مما يدخل في تكوين الجريمة تحت مسمى الركن المعنوي، فإذا اقتصر القانون على اشتراط الركن المادي دون الركن المعنوي، اعتبر القانون مخالفاً للدستور لقيام التجريم على غير ضرورة وتناسب.

وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (١٩) من الدستور المعدل بنصها على أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون." قد أكدت على كفالة الحرية الشخصية وجعلها أصلاً من الأصول والمقومات الدستورية الأساسية، بما مؤداه أن سلطة المشرع في تنظيمه

لها مقيدة بالحفاظ على وجودها وألا ينال التنظيم أو التحديد من جوهرها وألا يضع عليها من القيود ما يعصف بها وهو ما قررته المادة (٣١) من الدستور.

وحيث إن إعلاء الدستور من قدر الحرية الشخصية في المادتين (١٩) ، (٣١) منه مؤداه أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص العقابية يتعين أن تضبطها بمقاييس صارمة ومعايير حادة تلتزم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية. مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان أن لا تكون العقوبة أداة عارضة بالحرية بل تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، وأن تصاغ النصوص العقابية في حدود ضيقة تعريفا بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديدًا لماهيتها، لضمان ألا يكون التجهيل بها موطنًا للإخلال بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في نصه المذكور.

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل تنص على أن "العقوبة شخصية". ومفاد ذلك أنه لا يمكن إعتبار الشخص مسئولاً جنائياً إلا عن فعله أو امتناعه الشخصي، ويشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ويفترض هذا الإسناد توافر عنصرين الأول مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة والثاني توافر علاقة سببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.

ومعنى ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا بإعتباره فاعلاً لها أو شريكاً فيها. ومن المقرر أنه يعد فاعلاً للجريمة من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون لها أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها (المادة ٤٣ من قانون العقوبات) وفي هذا المقام لا يجوز الخلط بين المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية المفترضة، فالأولى تنصب على مساءلة الغير عن جريمة لم يسهم في ركنها المادي والثانية تنصب على مساءلة الغير عن جريمة لم يسهم في ركنها المعنوي بل يفترض في حقه توافر هذا الركن افتراضاً.

وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".

ويعتبر هذا الأصل مبدأً أساسياً لضمان الحرية الشخصية للمتهم ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، كما يعتبر هذا الأصل ركيزة أساسية للشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية وتتوافق هذه الركيزة مع الركيزة الأولى للشرعية الدستورية في

القوانين العقابية، وهي شرعية الجرائم والعقوبات ، ذلك أن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص - مادة (٢٠/ أ) من الدستور- يفترض حتما قاعدة أخرى وهي افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت جرمه طبقاً للقانون . كما أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها إعلان كفلهما الدستور بكل من نص الفقرة (ج) من المادة (٢٠) ونص الفقرة (أ) من المادة (١٩) فلا يجوز للسلطة التشريعية - وعلى ما سلف - أن تأتي عملاً يُخل بالحدود التي تفصل بين ولايتها ، والمهام التي تقوم عليها السلطة القضائية وعلى الأخص أن تغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصلية في أن تتحقق بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من قيام الدليل على إتيان هذه الجريمة في كل أركانها ، وعناصرها ، وأن المتهم كان مدركاً لحقيقتها ، ودلالاتها الإجرامية إدراكاً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً متجهاً لتحقيق نتيجتها المؤثمة.

وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك - ومن ناحية أخرى - وثيقة الصلة بالحق في الدفاع وتتمثل في حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها.

وحيث إن النص المطعون فيه قد افترض أن استيراد أو تداول المطبوع يفيد علم مستورده أو موزعه يقينا بما يتضمنه المطبوع من مواد منشورة به، وأن محتواها يكون جريمة معاقبا عليها ، يتوافر فيها القصد إلى ارتكابها وتحقيق نتيجتها المؤثمة، مقيماً بذلك قرينة قانونية على افتراض القصد الجنائي في حق المستورد عن جريمة لا تقع إلا عمداً.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد افترض المسؤولية الجنائية للمدعي استناداً إلى كونه المستورد والموزع للمطبوع السالف الذكر فإنه يكون قد نال من مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وانتقص من الحرية الشخصية للمدعي، وخالف مبدأ شخصية العقوبة، وأهدر مبدأ افتراض البراءة، وأخل بضوابط المحاكمة المنصفة، وما تشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع وبالتالي يكون مخالفاً لأحكام كل من الفقرة (أ) من المادة (٣٢) والفقرة (أ) من المادة (١٩) وال فقرات (أ) ، (ب) ، (ج) من المادة (٢٠) من الدستور.

وحيث إن مقتضى المادتين (٣٠) و (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية أن أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً

لذلك. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، وفي هذا الصدد تقرر المنكرة التفسيرية للدستور المعدل - تحديداً لمضمون ما نصت عليه المادة (٢/١٠٦) من الدستور - " وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر الأحكام الجنائية التي صدرت فإنه من باب أولى يسري ذات الحكم على كل الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية، إذ تعتبر هذه الدعاوى كأن لم تكن. " مما مؤداه استفادة كافة المخاطبين بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته من الحكم الصادر في الدعوى الماثلة فور النطق به ، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) سالفه الذكر والتي تنص على أن يقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (٨٣) من قانون الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ فيما نصت عليه من أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذه قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون"، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة